

La libre circulación de capitales se aplica sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para impedir las infracciones a su Derecho y normativas nacionales, en particular en materia fiscal y de supervisión prudencial de entidades financieras, establecer procedimientos de declaración de movimientos de capitales a efectos de información administrativa o estadística o tomar medidas justificadas por razones de orden público o de seguridad pública.

2.4. LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

2.4.1. Concepto

Se entiende por establecimiento aquella instalación material, estable y permanente de una persona física o jurídica nacional de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro, con el fin de ejercer en él una actividad no asalariada de naturaleza económica.

Según el artículo 49 del TFUE, la libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de sociedades –por sociedades se entiende las sociedades de Derecho civil o mercantil, incluso las sociedades cooperativas, y las demás personas jurídicas de Derecho público o privado, con excepción de las que no persigan un fin lucrativo–, en las condiciones fijadas por el país de establecimiento para sus propios nacionales.

A su vez, esta instalación material puede ser, bien una implantación principal, es decir, la creación o la transferencia de un centro de actividad por un nacional de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro; o, por el contrario, una implantación secundaria, es decir, la creación por una persona física o jurídica que explota un establecimiento principal en el territorio de un Estado miembro de una sucursal o filial en el territorio de otro Estado miembro.

En cambio, se entiende por prestación de servicios el ejercicio de actividades económicas no asalariadas a partir de un establecimiento situado en el territorio de un Estado miembro y destinado a un beneficiario que resida en el territorio de otro Estado miembro, con exclusión de toda instalación estable y permanente en el país destinatario de la prestación.

De conformidad con el artículo 57 del TFUE, con arreglo a los tratados, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas. El prestador de un servicio podrá, con objeto de realizar dicha prestación, ejercer temporalmente su actividad en el Estado miembro donde se lleve a cabo la prestación, en las mismas condiciones que imponga ese Estado a sus propios nacionales.

Añade el artículo 58 del TFUE que la libre prestación de servicios, en materia de transportes, se regirá por las disposiciones del título relativo a los transportes; la liberalización de los servicios bancarios y de seguros vinculados a los movimientos de capitales se realizará en armonía con la liberalización de la circulación de capitales.

Las diferencias entre el establecimiento y los servicios son las siguientes:

- El establecimiento supone una voluntad de permanencia y estabilidad en el Estado receptor, mientras que la prestación de servicios representa un carácter temporal y no estable.
- Además, el establecimiento implica siempre un desplazamiento efectivo mientras que la prestación de servicios no necesariamente supone un desplazamiento.

2.4.2. Ámbito de aplicación personal

Los beneficiarios del derecho de establecimiento y de prestación de servicios son tanto las personas físicas nacionales de un Estado miembro como las sociedades, entendiendo por sociedad lo establecido en el artículo 54 del TFUE, «de derecho civil o mercantil, incluso las sociedades cooperativas y demás personas jurídicas de derecho público o privado, con excepción de las que no persigan un fin lucrativo».

Además, estas sociedades han de cumplir con dos condiciones para poder beneficiarse del derecho de establecimiento. Según el mismo artículo 54 del TFUE, este derecho alcanza a «las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, Administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión».

2.4.3. Ámbito de aplicación material

El ámbito de aplicación material de las normas sobre derecho de establecimiento alcanza a todas las actividades económicas no asalariadas, con la única exclusión de las que estén relacionadas, aunque solo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público, y las que el legislador pueda decidir. El concepto de actividad no asalariada se contrapone al concepto de trabajo asalariado que es objeto de la libre circulación de trabajadores; esto es, se trata de actividades realizadas por cuenta propia y de forma independiente. Estas actividades alcanzan a cualquier sector económico, sea industrial, artesanal o profesiones liberales.

2.4.4. Contenido jurídico

El artículo 56 del TFUE establece: «Quedarán prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el destinatario de la prestación. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán extender el beneficio de estas disposiciones a los prestadores de servicios que sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Unión».

Por su parte, el artículo 49 del TFUE establece: «Quedarán prohibidas las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro».

2.4.5. Excepciones

La libertad de establecimiento y la prestación de servicios no están exentas de limitaciones, las cuales han sido recogidas en el texto del tratado. Por una parte, no se aplicarán a las actividades en un Estado miembro que estén relacionadas, aunque solo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público. Además, en ambas libertades, no se prejuzgará la aplicación de regímenes especiales para extranjeros que esté justificada por razones de orden público, seguridad y salud pública, de conformidad con el artículo 52 del TFUE.

Por otra parte, el artículo 58 del TFUE establece que la libre prestación de servicios, en materia de transportes, se regirá por las disposiciones del título relativo a los transportes. La liberalización de los servicios bancarios y de seguros vinculados a los movimientos de capitales se realizará en armonía con la liberalización de la circulación de capitales.

2.5. REFERENCIA A LA RED SOLVIT

Si bien el mercado interior funciona adecuadamente, en ocasiones se plantean problemas en aquellos casos en que alguna Administración pública nacional no respeta la normativa de la Unión.

La red SOLVIT (red de Resolución de Problemas en el Mercado Interior) ayuda a los ciudadanos y las empresas de un Estado delEEE (Unión Europea junto con Islandia, Noruega y Liechtenstein) cuando se enfrenten a un problema derivado de una posible aplicación incorrecta de la normativa sobre el mercado interior por parte de las Administraciones públicas en otro Estado miembro.

La red SOLVIT es una red de centros establecidos por los Estados miembros en el seno de sus propias Administraciones nacionales, que tiene por objeto ofrecer soluciones rápidas, eficaces e informales a los problemas que experimentan las empresas y los particulares cuando los derechos que les confiere la Unión en el mercado interior se ven denegados por las autoridades públicas nacionales. Esta red establece un centro SOLVIT por cada Estado miembro para abordar ese tipo de problemas; en España, es el ministerio competente en materia de Unión Europea. Es un caso SOLVIT todo problema transfronterizo ocasionado por la posible vulneración, por parte de una autoridad pública nacional, del derecho de la Unión aplicable al mercado interior, siempre y cuando dicho problema no sea objeto de procedimiento judicial a nivel nacional o de la Unión Europea.

En cada comunidad autónoma existe un punto de contacto SOLVIT. El ministerio competente (centro SOLVIT) se dirige al punto de contacto autonómico si la incorrecta aplicación de la legislación del mercado interior se produce en el ámbito autonómico.

En la Comunitat Valenciana el punto de contacto SOLVIT es la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y el Estado (de la Presidencia de la Generalitat).

2.6. EL RÉGIMEN DE COMPETENCIA

Como hemos indicado con anterioridad, el mercado interior o único abarca no solo las cuatro libertades fundamentales (la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales), sino también una política de libre competencia (régimen de competencia), junto con políticas comunes (la PAC, la PCC y la política común de transportes) y la coordinación de las políticas macroeconómicas.

También hemos indicado que en otros apartados del temario se exponen las políticas comunes (tema 40, salvo la PCC) y la coordinación de las políticas macroeconómicas (tema 40), quedando por exponer el régimen de competencia y la PCC.

Nos vamos a referir a continuación al régimen de competencia.

2.6.1. Objetivo

Como complemento a la libre circulación de los factores de producción, el Tratado de Roma creó el régimen de la competencia, cuyo objetivo es garantizar que la libre competencia no sea falseada en el mercado interior. Se trata de una competencia exclusiva de la Unión.

2.6.2. Contenido

La política europea de la competencia se articula a través de las siguientes vías:

1. Liberalización de los servicios de interés económico general.
2. Control de concentraciones de empresas de dimensión europea.
3. Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos entre las empresas (art. 101 del TFUE).
4. Prohibición de la explotación abusiva de la posición dominante en el mercado (art. 102 del TFUE).
5. Control de las intervenciones estatales que puedan afectar a la libre competencia dentro del mercado interior (arts. 107 a 109 del TFUE).

2.6.2.1. *Liberalización de los servicios de interés económico general*

En algunos países, determinados servicios esenciales (ejemplos: mercado del gas natural, mercado de la electricidad, telecomunicaciones, transporte aéreo, transporte ferroviario, servicios postales, etc.) siguen bajo control público y no están privatizados.

La Unión Europea impulsa a los Estados a que abran a la competencia estos servicios (también conocidos como «servicios de interés económico general»). Así, de conformidad con el artículo 106.2 del TFUE, las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las normas de los tratados, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada.

2.6.2.2. *Control de concentraciones de empresas de dimensión europea*

La realización del mercado interior y de la Unión Económica y Monetaria, la ampliación de la Unión Europea y la reducción de las barreras internacionales al comercio y a la inversión dan lugar a importantes reestructuraciones de las empresas, particularmente en forma de concentraciones.

Estas reorganizaciones se valoran de forma positiva en la medida en que responden a las exigencias de una competencia dinámica y pueden aumentar la competitividad en la Unión.

No obstante, es necesario garantizar que el proceso de reestructuración no cause un perjuicio a la competencia. Por ello, la Comisión lleva a cabo un control de todas las concentraciones de dimensión europea desde el punto de vista de su efecto sobre la estructura de la competencia en la Unión, alcanzando a las modificaciones estructurales importantes cuyo efecto en el mercado se extienda más allá de las fronteras nacionales de un Estado miembro.

Se considera que una concentración tiene dimensión europea cuando el volumen de negocios total de las empresas afectadas supera un umbral determinado con independencia de que las empresas participantes en la concentración tengan o no su sede o sus actividades principales en la Unión Europea, siempre y cuando realicen operaciones sustanciales en la misma.

2.6.2.3. *Prohibición de prácticas y acuerdos anticompetitivos entre las empresas*

El artículo 101 del TFUE dispone: «Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones entre empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consisten en:

- a) Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción.
- b) Limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones.
- c) Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento.
- d) Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva.
- e) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos».

Los acuerdos o decisiones prohibidos serán nulos de pleno derecho.

La regla general contenida en el artículo 101 del TFUE no obsta para que un acuerdo, que en principio debiera quedar prohibido en aplicación de dicho precepto, pueda ser, sin embargo, objeto de autorización mediante la concesión de una exención individual. El otorgamiento de esta exención lo debe acordar la Comisión, y solo podrá autorizarla cuando concurren los requisitos que indica el propio artículo 101 del TFUE: «Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas o cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos ni ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate».

Además, el Consejo habilitó a la Comisión para conceder exenciones por categorías de acuerdos considerados beneficiosos para el buen funcionamiento del mercado interior. Este tipo de acuerdos queda exento de notificación a la Comisión para conseguir la exención.

2.6.2.4. Prohibición del abuso de la posición dominante en el mercado

El artículo 102 del TFUE dispone: «Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.

Tales prácticas abusivas podrán consistir en, particularmente:

- a) Imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas.
- b) Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores.
- c) Aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen a estos una desventaja competitiva.
- d) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos».

Es la Comisión la institución que ostenta la competencia exclusiva sobre la aplicación de los artículos 101 y 102. El instrumento jurídico utilizado por la Comisión para comunicar a las empresas su posición ante las actuaciones empresariales que se le presentan es la «decisión», que ha de ser motivada y que es recurrible, según el artículo 263 del TFUE, ante el TJUE.

2.6.2.5. *Control de las intervenciones estatales que puedan afectar a la libre competencia dentro del mercado interior (ayudas de Estado)*

A) Regla general: salvo que los tratados dispongan otra cosa, son incompatibles con el mercado interior. Elementos constitutivos del concepto de ayuda estatal

El artículo 107.1 del TFUE subraya: «Salvo que los tratados dispongan otra cosa, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

La Comisión Europea ha perfilado el concepto de ayuda estatal del artículo 107.1 del TFUE. Según la Comisión Europea, los distintos elementos constitutivos del concepto de ayuda estatal son:

1. Las normas sobre ayudas estatales solo se aplican cuando el beneficiario de la medida de ayuda es una «empresa»:

El TJUE ha definido sistemáticamente a las empresas como entidades que ejercen una actividad económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación.

No afecta que tenga o no ánimo de lucro, lo importante es que ejerza una actividad económica; las entidades sin ánimo de lucro también pueden ofrecer bienes y servicios en un mercado. Para aclarar la distinción entre actividades económicas y no económicas, el TJUE ha dictaminado reiteradamente que cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado constituye una actividad económica.

En términos generales, salvo que el Estado miembro en cuestión haya decidido introducir mecanismos de mercado, las actividades que forman parte intrínseca de las prerrogativas de la autoridad oficial y que son desempeñadas por el Estado –en España: Gobierno, comunidades autónomas, entidades locales, etc.– no constituyen actividades económicas (por ejemplo: ejército, policía, organización, financiación y ejecución de las penas de prisión, etc.).

2. La imputabilidad de la medida al Estado:

La ayuda ha de ser imputable al Estado, incluyendo a los entes subestatales, como es el caso de las comunidades autónomas.

En los casos en que una autoridad pública concede una ventaja a un beneficiario, la medida es por definición imputable al Estado. Una medida no es imputable a un Estado miembro si el Estado miembro está obligado a ejecutarla en virtud del derecho de la Unión sin ninguna discrecionalidad. En tal caso, la medida se deriva de un acto del legislador de la Unión y no es imputable al Estado.

3. Su financiación mediante fondos estatales:

Por «fondos estatales» se entienden todos los fondos del sector público. La transferencia de fondos estatales puede revestir diversas formas, tales como subvenciones directas, préstamos, garantías, inversión directa en el capital de compañías y beneficios en especie. No es necesario que haya una transferencia positiva de fondos; es suficiente con que el Estado no haya percibido ingresos. Por ejemplo, un «déficit» en los ingresos fiscales y de la Seguridad Social generado por exenciones o reducciones fiscales en impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social concedidas por los Estados miembros, o la exoneración de la obligación de pago de multas u otras sanciones pecuniarias, cumple el requisito de fondos estatales del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Los fondos procedentes de la Unión (por ejemplo, de los Fondos Estructurales), o de instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), se consideran fondos estatales si las autoridades nacionales deciden en cuanto a su uso (en particular, la selección de beneficiarios). En cambio, si dichos fondos los concede directamente la Unión o la institución financiera internacional, sin decisión por parte de las autoridades nacionales, no constituyen fondos estatales.

4. La concesión de una ventaja:

Una ventaja es todo beneficio económico que una empresa no podría haber obtenido en condiciones normales de mercado. La forma concreta de la medida es irrelevante, así, se puede tratar de subvenciones, préstamos o créditos en condiciones ventajosas (sin interés o con interés inferior al de mercado), la condonación de débitos, garantías sobre préstamos, ventas de propiedades a precio inferior al de mercado, etc.

Siempre que la situación financiera de una empresa mejore como resultado de la intervención estatal en otros términos que las condiciones normales de mercado, hay una ventaja.

Existen casos controvertidos en los que ha tenido que ser el TJUE el que declara si existe o no ayuda del Estado. Uno de estos casos es el del «principio del inversor privado en una economía de mercado». Este es un principio central en el derecho de la Unión Europea en materia de ayudas del Estado. Se considera que, aunque se cumplan determinados requisitos propios de las ayudas del Estado, no confiere una ventaja a su destinatario y por tanto no es ayuda, si se realiza de conformidad con las condiciones normales de mercado; en definitiva, no es ayuda estatal si se aprecia que, en condiciones normales de mercado, un inversor privado –un inversor, un banco, un fiador, una empresa o un acreedor– de tamaño comparable hubiera realizado la misma inversión con ánimo de lucro. Un ejemplo en el que se invocó este principio de inversor privado en una economía de mercado lo encontramos en la Comunitat Valenciana, en la inversión que realizó la propia Generalitat para la construcción de la Ciudad de la Luz (complejo cinematográfico) en Alicante, si bien la Comisión Europea y después el Tribunal General consideraron que dicho principio no era aplicable en este caso.

Si un Estado miembro alega que actuó como un operador privado en una economía de mercado, cuando haya dudas, debe aportar pruebas que demuestren que la decisión de realizar la transacción fue adoptada sobre la base de evaluaciones económicas comparables a las que, en circunstancias similares, un operador racional en una economía de mercado (de características similares a las del organismo público en cuestión) habría realizado para determinar la rentabilidad o ventajas económicas de la transacción.

5. La selectividad de la medida:

No todas las medidas que favorecen a operadores económicos entran en el concepto de ayuda, sino solo aquellas que conceden una ventaja de manera selectiva a determinadas empresas o categorías de empresas o a determinados sectores económicos.

6. Su efecto sobre la competencia y los intercambios comerciales entre Estados miembros:

Se ha de tratar de una ayuda que «falsea o amenaza falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones» y solo «en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros» (art. 107.1 del TFUE). Se trata de dos elementos distintos y necesarios del concepto de ayuda, si bien se encuentran estrechamente vinculados.

Se considera que una medida concedida por el Estado falsea o amenaza falsear la competencia cuando es probable que mejore la posición competitiva del beneficiario frente a otras empresas con las que compite.

En cuanto a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda en los intercambios comerciales entre los Estados miembros, sino únicamente si la ayuda puede afectar a dichos intercambios. La cuantía relativamente reducida de una ayuda o el tamaño relativamente modesto de la empresa beneficiaria no excluyen *a priori* la posibilidad de que se vean afectados los intercambios entre Estados miembros (si bien cuando la cantidad de la ayuda es pequeña se considera que no tiene un efecto apreciable sobre el comercio y la competencia entre los Estados miembros –ayudas de minimis–).

B) Ayudas compatibles con el mercado interior

A continuación, en el artículo 107.2 del TFUE se recogen las ayudas que son compatibles con el mercado interior. Son:

- a) De carácter social, concedidas a los consumidores individuales siempre y cuando se concedan sin discriminación relativa al origen de los productos afectados.
- b) Las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.
- c) Las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, afectadas por la división de Alemania, en la medida en que sean necesarias para compensar las desventajas económicas que resultan de tal división. 5 años después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Consejo podrá derogar este punto.

Estas ayudas simplemente se han de comunicar a la Comisión Europea, sin que sea necesario la autorización de las mismas.

C) Ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado interior

En el artículo 107.3 se indican los supuestos en que las ayudas de los Estados podrán ser valoradas como compatibles con el mercado interior a criterio de la Comisión Europea. En este párrafo se establece que podrán ser compatibles con el mercado interior:

- a) Las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social.

- b) Las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
- c) Las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.
- d) Las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Unión en contra del interés común.
- e) Las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada a propuesta de la Comisión.

En relación con las ayudas del artículo 107.3 del TFUE, se han de notificar a la Comisión para que las autorice.

D) Procedimiento para la autorización de ayudas públicas

Las ayudas que requieren autorización han de ser autorizadas por la Comisión Europea. De acuerdo con el reglamento de procedimiento –Reglamento (UE) n.º 2015/1589, del Consejo, de 13 de julio, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del art. 108 del TFUE–, existe la cláusula de efecto suspensivo de modo que la ayuda que debe notificarse no podrá llevarse a efecto antes de que la Comisión adopte o deba considerarse que ha adoptado una decisión autorizando dicha ayuda.

El destinatario de la decisión de la Comisión será el Estado miembro interesado.

La ayuda resultará ilegal cuando los fondos públicos se hayan otorgado sin habersele comunicado previamente, cuando se conceda sin el visto bueno de la Comisión y cuando, tras una decisión negativa de la Comisión, la ayuda se ponga en marcha.

Si la ayuda ilegal hubiera sido ya concedida, se deberá recuperar del beneficiario salvo que ello fuera contrario a un principio general del derecho de la Unión Europea. La recuperación se efectúa con arreglo al derecho nacional del Estado miembro interesado. Las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas están sujetas a un plazo de prescripción de 10 años.

E) Ayudas públicas compatibles con el mercado interior exentas de la obligación de notificación a la Comisión: el reglamento de exención por categorías y las ayudas de minimis

- El reglamento de exención por categorías

El Reglamento (UE) n.º 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio, declara determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE.

Conforme a este reglamento, se establece que serán compatibles con el mercado interior y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del TFUE, las ayudas que cumplan todas las condiciones establecidas en el propio reglamento, dirigidas a las categorías de ayudas que concreta el mismo reglamento (beneficio de exención por categorías). Este reglamento se aplica a distintas categorías de ayuda tales como: ayudas para la protección del medio ambiente, ayudas

de investigación y desarrollo e innovación, ayudas a la formación, ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales, ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales, etc.

Para cada categoría de ayuda incluida en el ámbito de aplicación de este reglamento de exención por categorías se fijan umbrales (importes económicos de la ayuda) cuyo nivel tenga en cuenta la categoría de las ayudas. Las ayudas concedidas que rebasen dichos umbrales siguen estando sujetas a la obligación de notificación.

Se les aplica también la necesidad de que la ayuda implique un efecto incentivador. Se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado por escrito una solicitud de ayuda al Estado miembro de que se trate.

En materia de exención por categorías, hay normas específicas en caso de agricultura, pesca y acuicultura, en las que también se fijan umbrales y efecto incentivador.

Las ayudas públicas que se acogen al Reglamento de exención por categorías no se han de notificar a la Comisión Europea para que las autorice, si bien se han de comunicar a la Comisión Europea para que esté informada de su concesión.

- Las ayudas de minimis

La norma de minimis se aplica con el fin de que las subvenciones de poca cuantía estén exentas de la obligación de notificarlas y de comunicarlas a la Comisión. Quedan fijadas en el Reglamento (UE) n.º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre. La ayuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrá ser superior a 200.000 euros durante cualquier periodo de 3 ejercicios fiscales. La ayuda total de minimis concedida a una empresa que opere en el sector del transporte de mercancías por carretera no será superior a 100.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

Existen normas específicas de minimis en agricultura, pesca y acuicultura.

Las ayudas que se acogen a alguno de los Reglamentos de minimis ni se notifican ni se comunican a la Comisión Europea. Dado su escaso importe, se considera que no surten efecto en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y que por tanto no cumplen todos los requisitos para que sean consideradas ayudas del Estado.

- Ayudas públicas que, excepcionalmente, el Consejo puede decidir considerar compatibles con el mercado interior

Existe otra categoría de ayudas, de carácter excepcional, previstas en el artículo 108.2, párrafo tercero, del TFUE. Según esta norma, a petición de un Estado miembro, el Consejo podrá decidir, por unanimidad, que la ayuda que ha concedido o va a conceder dicho Estado sea considerada compatible con el mercado interior, cuando circunstancias excepcionales justifiquen dicha decisión.

F) Ayudas públicas concedidas por las comunidades autónomas

Tratándose de ayudas concedidas por las comunidades autónomas, la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE) –actualmente denominada Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE)– adoptó en su reunión de 29 de noviembre de 1990 un acuerdo sobre ayudas públicas. Conforme al mismo, la notificación de los proyectos de ayudas públicas

de las comunidades autónomas a la Comisión, así como las respuestas de las comunidades autónomas a las distintas comunicaciones de la Comisión en la materia, se articularán a través de la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas como órgano de coordinación en la materia (actualmente, la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea, Secretaría de Estado para la Unión Europea, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación).

Tratándose de la Comunitat Valenciana, es de aplicación el Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.

Este Decreto 128/2017, del Consell, es objeto de tratamiento específico en otro tema del programa, por lo que a continuación exponemos únicamente sus aspectos esenciales.

Regula los procedimientos de notificación y comunicación a la Comisión Europea, a través de la Administración general del Estado, de los proyectos para el establecimiento, la concesión o la modificación de ayudas públicas, así como establece un trámite de informe previo en la tramitación de los mismos, a fin de asegurar su adecuación a la política de la competencia de la UE.

Se aplica a las ayudas públicas que se establezcan, concedan o pretendan concederse con cargo a los presupuestos de la Administración de la Generalitat o del sector público instrumental, con independencia de si las ayudas están financiadas, total o parcialmente, mediante recursos de la UE o si se financian con fondos públicos propios.

Según el artículo 3 de este Decreto 128/2017, del Consell, referente a la obligación de notificar a la Comisión Europea y exenciones:

1. Todo proyecto de nueva ayuda o de modificación de una existente deberá notificarse previamente a la Comisión Europea para su autorización. Estas ayudas no podrán hacerse efectivas antes de dicha autorización o de que puedan considerarse autorizadas por la ausencia de decisión de la Comisión –cuando la Comisión no haya adoptado una decisión dentro del plazo de 2 meses desde el día siguiente a la recepción de la notificación, se considerará que la Comisión ha autorizado la ayuda; acto seguido el Estado miembro interesado podrá ejecutar las medidas tras haber informado previamente a la Comisión–.
2. No estarán sujetos a la obligación de notificación previa los proyectos de ayudas que se acogan a alguno de los reglamentos aprobados o que pueda aprobar la Comisión Europea que eximan, respecto a determinadas ayudas, de la obligación de notificación. No obstante, en estos supuestos será necesaria la comunicación a la Comisión de la información que se determine en la normativa de la Unión Europea, respecto del proyecto de ayuda.
3. Tampoco estarán sujetos a la obligación de notificación o comunicación los proyectos de ayudas acogidos a alguno de los reglamentos aprobados o que pueda aprobar la Comisión Europea para regular el denominado régimen de minimis.
4. No será obligatoria la notificación o comunicación de los proyectos de ayudas que no les sea de aplicación el artículo 107, apartado 1, del TFUE.

Los departamentos o entidades que pretendan establecer o modificar, bien un régimen de ayudas, bien una ayuda *ad hoc*, que cumplan los requisitos del artículo 107, apartado 1, del TFUE, remitirán a la dirección general competente en materia de coordinación y control de las ayudas públicas concedidas por la Generalitat, en el marco de la política de competencia de la UE, para su informe preceptivo y vinculante, los respectivos proyectos, la cual emitirá informe sobre su adecuación con el ordenamiento de la UE. La dirección general competente en materia de coordinación y control de las ayudas públicas

concedidas por la Generalitat, en el marco de la política de competencia de la UE, supervisará la documentación remitida y tramitará la notificación a la Comisión Europea a través del órgano competente de la Administración general del Estado.

El resto de ayudas a las que no les sea de aplicación el artículo 107, apartado 1, del TFUE deberán remitir el proyecto del instrumento jurídico que las vaya a regular, con inclusión de los motivos por los que no les resulta aplicable el artículo 107.1 del TFUE, a la Dirección General competente en materia de coordinación y control de las ayudas públicas concedidas por la Generalitat, en el marco de la política de competencia de la Unión Europea. Estos proyectos de ayudas a las que no les sea de aplicación el artículo 107, apartado 1, del TFUE deberán incluir en el proyecto del instrumento jurídico que regule la ayuda los motivos por los que no les resulta aplicable el artículo 107 del TFUE.

Por otra parte, según el Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, compete a la Dirección General de Fondos Europeos –dependiente de la Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación–, entre otras competencias:

- Preparar y presentar los proyectos de inversión susceptibles de ser cofinanciados con fondos europeos.
- Conocer, difundir, planificar y realizar el seguimiento de los fondos estructurales de la Unión Europea gestionados por los centros directivos de la Generalitat.
- Planificar la participación de la Generalitat en el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en su calidad de organismo intermedio de los programas operativos.
- Dirigir y controlar las ayudas públicas concedidas por la Generalitat, en el marco de la política de competencia de la Unión Europea.

2.7. POLÍTICA COMERCIAL COMÚN (PCC)

Como ha quedado ya expuesto, el mercado interior o único abarca las cuatro libertades fundamentales (la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales), una política de libre competencia (régimen de competencia), políticas comunes (la PAC, la PCC y la política común de transportes) y la coordinación de las políticas macroeconómicas.

En relación con la PCC, el TFUE no contiene una definición de esta política, si bien se puede considerar como la política consistente en la adopción por las instituciones europeas y bajo principios uniformes de las medidas que regulan las relaciones comerciales de la Unión Europea con terceros países.

Según el artículo 3 del TFUE, es una competencia exclusiva de la Unión.

La PCC se encuentra regulada en los artículos 206 y 207 del TFUE como uno de los ámbitos de la acción exterior de la Unión.

Los objetivos de la PCC responden a los principios de liberalización comercial y de competitividad internacional, comunes a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Dentro del contenido de la PCC es tradicional la distinción entre:

- La política comercial común autónoma (legislar unilateralmente sobre cuestiones comerciales); esto es, la adoptada unilateralmente por la Unión y referida a las importaciones, exportaciones y defensa contra prácticas comerciales de carácter anormal o ilícitas.

Uno de sus instrumentos es el AAC. La Unión Europea se basa en una unión aduanera que implica la utilización de un AAC para las importaciones de terceros países. La eliminación de aranceles interiores y el establecimiento del AAC culminó el 1 de julio de 1968. Los Estados miembros aplican un AAC a las mercancías importadas de fuera de la Unión Europea. La unión aduanera es competencia exclusiva de la Unión.

Otro instrumento es el control sobre las inversiones extranjeras directas. Se trata de controlar las inversiones de terceros países en sectores estratégicos y asegurarse así de que no supongan una amenaza para la seguridad o el orden público. La Unión tiene uno de los regímenes de inversión más abiertos del mundo; no obstante, en algunos casos puede que los inversores extranjeros pretendan adquirir activos estratégicos que les permitan controlar las empresas europeas cuyas actividades son vitales para la seguridad y el orden público de la Unión. Se trata, en particular, de actividades relacionadas con el funcionamiento o el suministro de tecnologías esenciales, infraestructuras o con información sensible, lo que permitiría a terceros países utilizar estos activos no solo en detrimento de la ventaja tecnológica de la Unión, sino también para poner en peligro la seguridad o el orden público en la Unión Europea.

También se prevén medidas de salvaguardia ante acuerdos comerciales: cláusulas de salvaguardia u otros mecanismos de retirada temporal de las preferencias arancelarias o del régimen preferencial. Su finalidad es proteger a un sector económico específico de la UE frente a un aumento de las importaciones de cualquier producto que cause, o pudiera causar, graves daños a dicho sector.

Por último, existen instrumentos de defensa comercial, disposiciones de la Unión para ayudar a protegerse contra las prácticas comerciales desleales (medidas *antidumping*; el *dumping* es la situación que se produce cuando una empresa de un tercer país comercializa productos en la Unión Europea a un precio que se encuentra por debajo del precio de venta en su mercado nacional o del coste de producción) garantizando un comercio libre y justo. Por ejemplo, se aplicarán a los casos en los que los precios de los productos importados se reducen artificialmente debido a una intervención estatal del tercer Estado; frente a esta práctica desleal se permite la imposición de aranceles más elevados a las importaciones.

- La política comercial común convencional (celebrar bilateral o multilateralmente acuerdos comerciales internacionales); esto es, la basada en la celebración de acuerdos comerciales o en acuerdos de asociación –estos últimos incluyen acuerdos políticos más amplios, art. 217 del TFUE–, con otros países o con organizaciones internacionales.

La Unión Europea ha celebrado acuerdos comerciales con cerca de 100 países diferentes. Cabe también citar los acuerdos relativos a la creación del EEE, los convenios con los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) –en la actualidad está vigente el Acuerdo de Cotonú–, los acuerdos de asociación euromediterráneos y los acuerdos de asociación con los países de Europa central y oriental (PECO).

Cada acuerdo es único y puede incluir reducciones de aranceles, normas sobre cuestiones como la propiedad intelectual o el desarrollo sostenible.

La Unión también colabora con la OMC para contribuir a establecer las normas del comercio mundial y eliminar los obstáculos a los intercambios entre los miembros de la OMC.

3. LAS COMPETENCIAS Y GARANTÍAS SOBRE EL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA (ELSJ)

El origen del ELSJ se encuentra en las consecuencias derivadas de la existencia de un mercado interior, con la desaparición de controles fronterizos y la libre circulación de personas y capitales, que pro-

picia el planteamiento de problemas comunes de delincuencia. Por ello, diversos Estados comenzaron a colaborar sectorialmente y al margen de las comunidades en estos temas.

Así, una reunión del Consejo Europeo en Roma en 1975 decidió la creación del Grupo de Trevi, poniendo en marcha a partir del año siguiente una red intergubernamental especializada en terrorismo, violencia política y delincuencia.

En 1985 y 1990 se firmó el Convenio y Acuerdo de Schengen, mediante los que los Estados firmantes suprimían los controles en las fronteras interiores (entre esos países) y reforzaban conjuntamente los controles a las fronteras exteriores (con terceros países), garantizando la cooperación policial y aduanera entre ellos.

Posteriormente, en 1992, el Tratado de Maastricht incorporó gran parte de esta preocupación a su articulado, creando el tercer pilar, por entonces denominado cooperación en asuntos de justicia e interior (CAJI).

El Tratado de Ámsterdam, de 1997, introdujo importantes modificaciones al comunitarizar gran parte de la CAJI, dejando en el tercer pilar solo lo relativo al ámbito penal e incorporando a la Unión Europea el acervo Schengen. Fruto de este proceso, el Tratado de Ámsterdam rebautizó el tercer pilar con el nombre de cooperación policial y judicial en materia penal (CPJP).

Por último, en 2007, el Tratado de Lisboa culminó el proceso de comunitarización de este pilar, reconociendo a la Unión Europea competencia en materia policial y penal, por lo que, desde su entrada en vigor, el ELSJ (su nueva denominación) pasa a ser considerado una política de la Unión.

Se regula en el título V de la parte III del TFUE (arts. 67 a 89).

3.1. DISPOSICIONES GENERALES

Esta política no se aplica en todos los Estados miembros, pues Irlanda y Dinamarca tienen un estatuto especial.

En el artículo 67 del TFUE se especifican los tres ámbitos de actuación de esta política (libertad, seguridad y justicia). En concreto, dispone que el ELSJ:

- Garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países.
- La Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales.
- La Unión facilitará la tutela judicial, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil.

No obstante, el tratado especifica una serie de materias vetadas al ELSJ y que, por tanto, siguen estando en manos de los Estados. De conformidad con el artículo 4.2 del TUE, la Unión Europea «respe-

tará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro».

3.2. LIBERTAD: POLÍTICAS SOBRE CONTROLES EN LAS FRONTERAS, ASILO E INMIGRACIÓN

Los artículos 77 a 80 del TFUE desarrollan el componente del ELSJ relacionado con la libre circulación de las personas y, en concreto, su control.

Respecto al control de las fronteras, dispone el artículo 77 del TFUE que la Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo:

- a) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.
- b) Garantizar los controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores.
- c) Instaurar progresivamente un sistema integrado de gestión de las fronteras exteriores.

Respecto a la inmigración, la Unión desarrollará una política común destinada a garantizar, en todo momento, una gestión eficaz de los flujos migratorios, un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros, así como una prevención de la inmigración ilegal y de la trata de seres humanos y una lucha reforzada contra ambas. No obstante, el desarrollo de una política común de inmigración no impide que los Estados miembros puedan seguir estableciendo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 79.5 del TFUE, volúmenes o cuotas de inmigrantes de terceros países (no respecto de la inmigración intracomunitaria).

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) es la agencia que se encarga de ayudar a los Estados miembros de la Unión Europea y a los restantes Estados del espacio Schengen a gestionar las fronteras exteriores de la Unión Europea, fronteras marítimas, terrestres o en aeropuertos internacionales. También participa en operaciones de búsqueda y salvamento.

3.3. SEGURIDAD: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PENAL Y LA COOPERACIÓN POLICIAL

Con respecto a la cooperación judicial en el ámbito penal en la Unión, esta se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros reguladoras de aspectos del ámbito penal y dimensión transfronteriza (como el terrorismo, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada).

3.4. JUSTICIA: LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL

El Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas para garantizar, entre otras: el reconocimiento mutuo, entre los Estados miembros, de las

resoluciones judiciales y extrajudiciales; la cooperación en la obtención de pruebas; una tutela judicial efectiva; la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles; el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios; y el apoyo a la formación de magistrados y del personal al servicio de la Administración de justicia.

3.5. EL SISTEMA SCHENGEN COMO PARTE DEL ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

El modelo de Schengen fue creado por el Acuerdo de 14 de junio de 1985 y el Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990 (aunque entró en vigor el 26 de marzo de 1995), y en él participan 30 Estados: Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo (desde su creación), Italia (1990), España y Portugal (1991), Grecia (1992), Austria (1995), Dinamarca, Finlandia y Suecia (1996), Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría, Polonia, Malta y Chipre (2004), Rumanía y Bulgaria (2007) y Croacia (2013). Irlanda no pertenece al espacio Schengen. Junto a estos 26 Estados de la Unión, el Espacio Schengen se completa con la participación de cuatro Estados no miembros: Islandia y Noruega (1996), Suiza (2005) y Liechtenstein (2008).

No obstante, Rumanía, Bulgaria y Chipre no se encuentran plenamente integradas en el espacio Schengen, por lo que actualmente sigue existiendo el control de fronteras interiores en estos países.

El objetivo fundamental de Schengen es crear entre los Estados participantes un marco de cooperación que permitiera a estos Estados llevar a cabo la supresión de las fronteras interiores y «compensar» los riesgos para la seguridad que inevitablemente han de derivarse de esa eliminación de fronteras en el espacio europeo.

Una complicada red de normas, reglamentaciones, prácticas administrativas y mecanismos operativos vinculados a estos problemas constituyen el denominado «acervo Schengen». Una regulación referida fundamentalmente a:

- a) El cruce de fronteras interiores (supresión de controles y restablecimiento en caso de orden público o seguridad nacional).
- b) Control del cruce de fronteras exteriores (política de visados de corta y larga duración, medidas sobre inmigración ilegal, condiciones de circulación de extranjeros y acuerdos de readmisión).
- c) Cooperación policial y judicial.
- d) Protección de datos de carácter personal.

Con el Tratado de Ámsterdam de 1997 se integró el acervo de Schengen en la normativa de la Unión Europea (Protocolo n.º 2, anexo al Tratado de Ámsterdam).

